

1500518-56.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARINA MIRANDA BELOTTI HASMANN

Comarca: Itajobi

Foro: Foro de Itajobi

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Penal e ainda fora preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, em que pese os réus sejam primários, os elementos constantes dos autos indicam, à saciedade, que se dedicam à prática de atos ilícitos, em especial o tráfico de drogas, fazendo dele seu meio de vida. Inviável, assim, a aplicação do redutor:

Cálculo da Pena Tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itajobi

Foro de Itajobi

Vara Única

Rua Said Farhat, 100, Itajobi-SP - cep 15840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500518-56.2021.8.26.0558 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500518-56.2021.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2329937/2021 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 21765186 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 1073/21/714 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 2329937 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY GUILHERME NOVAIS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA MIRANDA BELOTTI HASMANN

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou ALAN SANTOS SILVA e WESLEY GUILHERME NOVAIS SANTOS, qualificados nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 21h00, na Rua Mário Pessoa de Lima nº 350 - fundos, bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Itajobi, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com o adolescente K.F.R., guardavam, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) eppendorfs de

cocaína, na forma de crack, e 14 (catorze) eppendorfs de cocaína, assim consideradas substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante delito fora convertida em preventiva (fls. 90/94).

Notificados (fls. 156 e 158), os acusados apresentaram defesa às fls. 172/176 e 177/179.

Às fls. 180/183 foram analisadas as preliminares arguidas, recebida a denúncia, designada audiência e analisado os requerimentos formulados.

Os réus foram citados às fls. 244 e 245.

Às fls. 247/248 a prisão preventiva fora reanalisada.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação (fls. 23), fotos (fls. 24/25) e laudo do exame químico toxicológico (fls. 152/154).

A autoria, de igual forma, é certa.

Wesley José Gonçalves, policial militar, disse que já tinham recebido diversas denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas no local, as quais indicavam inclusive o nome de Wesley, vulgo "Porcão"; no dia dos fatos receberam nova denúncia. No local, visualizaram um indivíduo pegando algo da mão de outro e deixando o local. Abordado na Avenida de Catanduva, tal pessoa disse que era usuário de drogas e tinha acabado de comprar dois eppendorfs de cocaína de uma pessoa chamada Alan, entregando a ele uma nota de R\$20,00; em revista, com o usuário encontraram dois eppendorfs em sua meia. Retornando ao local objeto das denúncias, abordaram Alan em frente à residência, e com ele encontraram dois eppendorfs de crack e uma nota de R\$20,00. Outros dois indivíduos, que estavam no corredor da residência, correram para os fundos tentando pular o portão, foram abordados e resistiram a prisão; Wesley, vulgo "Porcão", arremessou uma sacola contendo diversos eppendorfs de crack, com as mesmas características daqueles apreendidos com o usuário de drogas e com o réu Alan; com o menor encontraram dinheiro. Realizada vistoria no imóvel, em cima do telhado encontraram uma sacola contendo cerca de 14 eppendorfs com cocaína. Questionados, os réus confirmaram a prática do crime de tráfico de drogas; o adolescente disse que estava no local vendendo droga para os réus. O local da prisão já era conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas e outros policiais já haviam inclusive efetuado apreensões naquela residência. As denúncias geralmente indicavam o nome de Wesley, vulgo "Porcão", com outros indivíduos. O usuário indicou a pessoa que lhe vendeu droga pelo nome de "Alan".

Sérgio Rodrigo de Souza Sampaio, policial militar, disse que o local dos fatos é conhecido como "biqueira". Na data, receberam nova denúncia da prática do crime de tráfico de drogas no local, a qual mencionava o vulgo "Porcão". Já sabendo que Wesley, vulgo "Porcão", tem por costume sair correndo das abordagens e pular telhado, já solicitou o apoio de outras viaturas. Nas proximidades do local indicado, visualizaram uma situação típica de venda: uma pessoa saindo da residência e entregando um objeto a outra pessoa. Retardaram um momento a abordagem, viram essa pessoa guardando o objeto na meia e indo embora. Optaram por abordá-lo nas proximidades; na busca pessoal, encontraram dois eppendorfs de crack; questionado, disse que era usuário e confirmou que tinha acabado de comprar a droga da pessoa de Alan, descrevendo suas vestes, e disse que pagou R\$10,00 por cada eppendorf, entregando uma nota de R\$20,00. Retornando ao local, abordaram o réu Alan em frente da residência; com ele encontraram dois eppendorfs com as mesmas características dos encontrados com o usuário e uma nota de R\$20,00. Duas pessoas que estavam no corredor da residência correram para os fundos; no encalço, visualizaram o réu Wesley dispensando uma sacola; abordados, retornaram para

verificar e na sacola tinham 23 eppendorfs de crack, os quais possuíam as mesmas características daqueles encontrados com o réu Alan e com o usuário de drogas; com o menor encontraram R\$322,00 em notas diversas. Questionados, o adolescente disse que era da cidade de Tabapuã, de pronto confessou a traficância e confirmou que o dinheiro era proveniente da venda de drogas. O réu Wesley já era conhecido pela prática de atos infracionais relativos a tráfico de drogas; o réu Alan já tem uma condenação por tráfico de drogas. A testemunhas ainda esclareceu que geralmente recebem denúncias via telefone da Base Policial e é comum também que pessoas lá compareçam e, pedindo anonimato, fazem denúncias. Por fim, afirmou que o apoio chegou no local dos fatos e que tal fato consta no BOPM; no BO Civil, o Delegado entendeu por bem não constar. Xisse, por fim, que a viatura era caracterizada. Marcelo Júlio Rossi Aranha, vulgo "Lobinho", afirmou que era usuário de crack. No dia dos fatos, disse que foi abordado em um Bar, situado no Jardim dos Ipês, e com ele encontraram dois pinos de drogas, os quais, porém, não tinham qualquer relação com os réus. Disse que tem amizade com o réu Wesley, vulgo "Porcão", e que não conhece o menor. Negou que tenha dito ao Delegado de Polícia que adquiriu a droga dos réus; afirmou que comprou a droga no Bar em que estava, de pessoas desconhecidas. Não sabe a razão pela qual foi abordado. Afirmou não ter sofrido qualquer tipo de constrangimento por parte dos policiais militares ou do Delegado. Os acusados negaram em juízo a prática do crime descrito na denúncia. O réu Alan disse que de fato foi abordado na frente da residência, mas estava ali para adquirir droga e tinha R\$40,00. Comprou duas porções, no valor de R\$20,00, sobrando R\$20,00. Não sabe dizer quem mora no local, mas sabia que lá vendida entorpecente. Voltou a usar droga há 5 meses. Recorda-se de ter adquirido droga do "Gibi", da cidade de Catanduva. Já tinha sido abordado pelo Policial Sampaio, mas não possui nada contra os policiais militares. Conhecía o Wesley, pois é amigo do Kesley, irmão dele; não conhecia o menor. Afirmou que os policiais chegaram com um alicate de cortar cadeado; viu que os meninos - Wesley, o menor e o "Gibi" - correram para os fundos da residência. Disse que no local tinha câmera de segurança e tinham outras pessoas na rua; não mencionou tal fato na Delegacia. Por fim, questionado, disse que quando afirmou "quando foi atender a porta", na verdade queria dizer "quando foram atender o portão".

O réu Wesley, por sua vez, disse que de vez em quando trabalhava de servente de pedreiro, é usuário de drogas e no dia dos fatos estava ali para usar entorpecente; no momento em que os policiais chegaram, estavam fumando crack; naquele dia, o menor deixou que consumisse a droga no local. O menor, que é morador de outra cidade, ao ser questionado, confessou aos policiais que a droga e o dinheiro eram dele. Reside naquele local uma pessoa chamada Márcio, que é segurança. Aquele local sempre foi uma biqueira; um "muleque" trazia a droga de Catanduva para o Márcio vender. Quando ia adquirir droga, o Márcio dizia que poderia pular o muro. Já esteve na Fundação Casa quatro vezes. Afirmou que no dia dos fatos adquiriu a droga do menor K.; conheceu-o no dia dos fatos; conhecia o Alan de vista pois ele é amigo do seu irmão Kesley; Alan também foi naquele dia comprar droga; pelo o que sabe, também foi o K. quem vendeu para o Alan. No momento em que a polícia chegou, estava o "Paraná", que também estava usando droga no local. "Galego" é o Roberto; neste dia ele não estava no local. "Gibi" é de Catanduva e na hora que a polícia chegou ele não estava lá; naquele dia, foi embora mais cedo. No momento da prisão, já tinha feito uso de crack.

A versão apresentada pelos acusados, porém, em quase sua totalidade, contrasta com o quadro probatório.

Inicialmente, não se vislumbra qualquer irregularidade na conduta adotada pelos policiais militares.

A afirmação de que o local dos fatos já era conhecido como ponto de tráfico de drogas foi confirmada em juízo pelos réus, os quais, inclusive, justificaram que lá estavam para adquirir droga. Assim, justamente porque não é atribuição dos policiais militares investigar, é que, diante da notícia de que um crime estava em curso, tinham o poder-dever de verificar a sua efetiva ocorrência.

As razões pelas quais a polícia civil aparentemente não tinha investigação em curso não tem o condão de afastar tal realidade e tampouco de nulificar a atuação da

Polícia Militar. Destaco novamente que os réus confirmaram em juízo que o local dos fatos era uma “biqueira”.

Assim, tratando-se de local conhecido pela venda de drogas, somado as circunstâncias fáticas – denúncia anônima, visualização da entrega de algo a um terceiro, abordagem de usuário, apreensão de drogas e dinheiro – permitiam a diligência realizada pelos policiais e, por tratar-se de crime permanente, desnecessário o pedido de mandado de busca e apreensão.

Na lição do Desembargador Zorzi Rocha, do E. Tribunal de Justiça deste Estado, “O tráfico de drogas é crime permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas, seja nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, seja nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de busca e apreensão, ainda mais quando o local era conhecido pela prática do crime espúrio, de modo que não se há de falar em ilicitude da prova. De outra parte, em se tratando de tese de eventual vício na prisão em flagrante, sua repercussão seria tão somente limitada à questão da prisão, sabido que na fase extrajudicial não existe nulidade porque não há atos processuais e, portanto, não há formalidade a ser resguardada” (TJSP, Apelação Criminal nº 1501421-19.2018.8.26.0228, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Zorzi Rocha, d.j. 5 de novembro de 2020).

No mesmo sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO. QUESTÃO SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes). II - Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada no fato de que o ora recorrente já fora antes condenado pela prática do mesmo delito. Recurso ordinário desprovido” (STJ, RHC nº 68994/ES, C. 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, d.j. 16.08.2016).

Denúncia anônima, isoladamente, não autoriza a busca domiciliar sem autorização judicial. Mas o caso em apreço se afasta diametralmente de tal situação.

O receio de cidadãos em delatar fatos ilícitos, bem como de usuários de drogas confirmar em juízo a pessoa que lhe vendeu o entorpecente é fato notório e não passou despercebido pelos nossos Tribunais.

O Desembargador Gilberto Passos de Freitas já advertia que, “como é sabido, em crimes relacionados com o tráfico de drogas, a oitiva de testemunhas alheias aos quadros policiais é quase impossível, na medida em que as pessoas que eventualmente tenham conhecimento dos fatos têm medo de represálias, de vingança” (Apelação Criminal nº 348.110-3/1-00, d.j. 30 de abril de 2002, in JTJ263/517).

No mesmo sentido, reconheceu recentemente o Desembargador Marcos Correa, no julgamento da Apelação Criminal nº 1501018-73.2020.8.26.0618: “Quanto à ausência de testemunhas fora dos quadros policiais, como sabido, na maioria das ocorrências, não é raro que terceiros se esquivem de colaborar com o Estado em razão do medo de represálias ou por se sentirem intimidados pelos procedimentos” (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 20 de janeiro de 2022).

Não por outra razão que a retratação em juízo de acusados e testemunhas, quando isoladas no quadro probatório, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal. Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (15 PORÇÕES DE CRACK) – ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA –

IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS QUE VISUALIZARAM O ATO DE MERCANCIA E REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE - RETRATAÇÃO DO USUÁRIO INÓCUA - CONDENAÇÃO DE RIGOR - PENA FIXADA DE FORMA MOTIVADA - A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OBSTA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO - O SOMATÓRIO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAMOREGIME FECHADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO (TJSP, Apelação Criminal nº 0022622-64.2015.8.26.0320, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, d.j. 10 de novembro de 2021).

Assim, as críticas genéricas tecidas à atuação da Polícia Militar desta Comarca são isoladas e parecem ser fruto de teses acadêmicas que, no caso em apreço, não estão ancoradas em qualquer dado fático.

É certo, porém, que no presente feito há divergência entre os laudos médicos realizados antes da apresentação dos autuados em solo policial e aquele realizado na Cadeia Pública. Embora deva ser apurado, tanto que as providências já foram determinadas por este Juízo, extremamente prematuro apontar a existência de tortura e concluir que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante foram os supostos autores e, por consequência, que seus depoimentos prestados em juízo são desprovidos de idoneidade.

No caso em apreço, e apenas a título de exemplo, sequer se tem a informação de que o transporte dos autuados, após a apresentação na Delegacia de Polícia, se deu pela Polícia Militar e, em especial, pelos mesmos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Em consequência, sendo os depoimentos coesos, seguros, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos de prova, não há como pretender afastar a credibilidade dos testemunhos prestados por policiais militares. Quanto ao valor do depoimento de policiais, é preciso ter em mente que são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade, até porque o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir crimes. Assim, presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade.

Tal conclusão está alicerçada em remansosa jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Versão do réu que restou isolada nos autos - Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Inviabilidade - Condenação era de rigor - Redução da pena base - Impossibilidade - Aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 - Não preenchimento dos requisitos legais Réu portador de maus antecedentes e reincidente - Regime fechado mantido - Sentença mantida - Recurso defensivo improvido (TJSP, Apelação Criminal nº 1500724-38.2019.8.26.0559, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Edison Brandão, d.j. 07 de abril de 2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Absolvição Descabimento - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Negativa de autoria que veio em versão pouco crível - Imprestabilidade do depoimento dos agentes da lei que não se justifica - Desclassificação - Descabimento - Dosimetria bem realizada - Bis in idem pelo reconhecimento da reincidência e afastamento da redutora de pena Inocorrência - Regime fechado bem eleito - Recurso desprovido (TJSP, Apelação Criminal nº 1501018-73.2020.8.26.0618, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Correa, d.j. 20 de janeiro de 2022).

Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo e tem em depósito 53,7 gramas de cocaína sob a forma de "crack" (27 pedras), 63,4 gramas de cocaína em pó (61 porções) e 97,5 gramas de maconha (48 unidades), para fins de tráfico - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade - No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial

não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes Alegação de porte de entorpecente Agente que traz consigo e tem em depósito quantidade significativa de substância estupefaciente de grande poder viciante Elementos fortemente indicativos de que o tóxico se destinaria ao tráfico (...) (TJSP, Apelação Criminal nº 1500069-45.2020.8.26.0587, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, d.j. 17 de dezembro de 2021).

E a análise detida dos elementos de prova indicam que a retratação em juízo da testemunha Marcelo e a versão dada pelos réus é que destoam do quadro probatório. De fato, há importante contradição na versão dada pelos réus. Na Delegacia de Polícia, ambos afirmaram que a droga pertencia exclusivamente ao menor K. (fls. 12 e 13). Em juízo, o réu Alan afirmou que adquiriu a droga de uma pessoa conhecida pelo vulgo de "Gibi", da cidade de Catanduva, e quando os policiais chegaram, Wesley, o menor K. e o "Gibi" correram para os fundos da casa. Wesley, por sua vez, afirmou em audiência que adquiriu e obteve autorização do menor K. para usar droga no local e que a pessoa conhecida por "Gibi" já tinha ido embora, não estando presente no momento da abordagem policial. E, pela dinâmica narrada pelos próprios réus, não é possível que Alan tenha chegado no local dos fatos antes de Wesley. Ademais, pretender justificar a contradição no suposto efeito de droga é absolutamente inverossímil.

Importante destacar, ainda, que em solo policial (fls. 29 e 31), o réu Alan afirmou que residia Rua Mário Pessoa de Lima nº 350 - fundos, bairro Jardim dos Ipês, em Itajobi, justamente o local dos fatos. Em juízo, porém, disse que não sabia quem eram os moradores daquela residência. Ainda de acordo com as informações prestadas em solo policial, tanto Alan quanto Wesley, na época dos fatos, estavam desempregados (fls. 29, 31, 33 e 35).

Aliás, a fala do réu Alan "quando foi atender a porta", ao invés de se mostrar um ato falho, encontra efetivo respaldo no quadro probatório. Os policiais afirmaram em todas as vezes em que ouvidos que avistaram alguém entregando algo a outrem, em situação típica de comércio de drogas e em local conhecido como ponto de venda de entorpecente; abordado próximo ao local, o terceiro confirmou aos policiais militares e ao Delegado de Polícia (fls. 10) que acabara de adquirir a droga apreendida em sua posse do réu Alan, pagando por ela R\$20,00 em uma única nota; retornando ao local dos fatos, Alan fora abordado ainda na frente da residência e em sua posse encontrados mais dois eppendorfs de cocaína e uma nota de R\$20,00; o réu Wesley e o menor K., diante da chegada da polícia, correram para os fundos da residência; na residência (nos fundos e em cima do telhado) foram encontradas mais porções de droga, as quais possuíam a mesma características daquelas apreendidas em poder de Alan e da testemunha Marcelo.

Neste contexto, a realização de reconhecimento pessoal pela testemunha Marcelo da pessoa que lhe vendeu o entorpecente não se mostrava indispensável. E, considerando que consta dos autos apenas que referida testemunha "aguardou na viatura a abordagem realizada pelos policiais militares" e que, "Após, veio com a polícia militar até esta Delegacia de Polícia para registro da ocorrência", tal prova poderia ter sido pleiteada pela Defensoria Pública no dia da comunicação da prisão em flagrante (fls. 77 e 90) ou pela Defesa no curso da instrução processual, já que a alegada imprestabilidade de sua realização não se confirmou.

Importante consignar, ainda, que a afirmação de que no local dos fatos possuía câmera de segurança poderia ter vindo acompanhada de prova, já que a efetiva constatação de tal fato independia da atuação policial. Com a prova da existência de câmeras, a Polícia Civil poderia ter sido provocada para verificar a existência de imagens ou mesmo tal pedido sido formulado em juízo. De igual forma, afirmar que os fatos foram presenciados por terceiros, mas não indicar nomes, não é apto sequer a indicar a suposta falha na investigação. E tal conclusão decorre simplesmente do cotejamento das declarações e provas constantes dos autos.

O quadro fático ainda afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para o

crime de uso, diante das circunstâncias da prisão, quantidade e forma como acondicionado o entorpecente (artigo 28, §2º, da Lei 11.343/2006). Ademais, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo incriminador (descrição da lei), que, no caso, constitui o fato de os réus guardarem, terem em depósito e trazerem consigo substância entorpecente com a finalidade de comércio. Já se decidiu:

“O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda” (TJSP, Ap. 316.892.3/0, 4ª Câm. de Férias de Janeiro de 2001, j. 12-6-2001, rel. Des. Hélio de Freitas, RT 793/576).

De igual forma, a conduta de atender a porta, entregar o entorpecente e receber o dinheiro do usuário não pode ser tida como de menor importância.

Configurado, pois, o crime de tráfico de drogas, a condenação se impõe. Passo, assim, à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal em razão da diversidade e alto poder destrutivo das drogas apreendidas (cocaína e cocaína na forma de crack). Fixo-a, assim, em 5 anos e 8 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em razão do aumento de 1/6.

Na segunda fase, em razão da menoridade relativa, a pena deve retornar ao mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, comprovada a efetiva participação do menor na atividade criminosa, com quem, inclusive, fora apreendido a quase totalidade do dinheiro – fato a indicar, inclusive, importantíssima função assumida por ele na atividade criminosa –, configurada está a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Considerando o destaque da função desempenhada pelo menor, a quem, inclusive, inicialmente fora atribuída toda a culpa, revelando, ainda, mais uma das vantagens de se ter um menor participando da prática criminosa, aumento a pena em ¼, fixando-a em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, no mínimo a unidade.

Inviável, de outro lado, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. “Como se vê, esta norma possui natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta minorante é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo 33, “caput”, ao fato delituoso que represente menor gravidade. Ou seja, reduzida ofensa, menor perigo social, uma vez que a norma aplica-se às pessoas que não tenham envolvimento anterior com crimes e que, a despeito de terem praticado uma conduta relacionada ao tráfico de drogas, não se dediquem à traficância ou faça parte de organização criminosa (...)” (TJSP, Apelação Criminal nº 0004927-12.2017.8.26.0358, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rl. Des. Marcos Correa, d.j. 5 de novembro de 2020).

A análise detida das circunstâncias fáticas indica, à sociedade, que conduta praticada pelos réus não pode ser tida como de menor gravidade. “Observa-se, por oportuno, que a natureza e variedade de entorpecentes devem ser consideradas nas diversas fases da dosimetria (art. 42 da Lei Antidrogas), mas sob perspectivas diversas na primeira, são consideradas como fatores atentatórios à saúde pública, e na fixação da pena final são vistas sob o prisma do grau de envolvimento do réu com estrutura criminosa destinada ao tráfico. Assim, não há que se falar em bis in idem” (TJSP, Apelação Criminal nº 1500366-61.2019.8.26.0272, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Reinaldo Cintra, d.j. 19 de agosto de 2020).

Ademais, o réu Alan, que estava desempregado, responde a outro processo também pela prática do crime de tráfico de drogas. No feito nº 1500133-20.2021.8.26.0264, mencionado na F.A., consta que no dia 21 de abril de 2021 fora preso em flagrante delito por trazer consigo 56,35 gramas de maconha e 3 eppendorfs de cocaína.

Concedida liberdade provisória, poucos meses depois novamente fora preso em flagrante delito pela prática do mesmo delito.

No que toca ao réu Wesley, igualmente desempregado, embora os inúmeros antecedentes da infância e juventude (fls. 73/74) não possam ser utilizados como maus antecedentes, indiscutivelmente comprovam que se dedica, há anos, à prática de atos infracionais graves, pelos quais já lhe foram impostas medidas socioeducativas de semiliberdade e internação. Pelo descumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, o réu também já cumpriu internação sanção.

Atingida a maioridade, a situação não se alterou: é investigado no inquérito policial nº 1500082-72.2022.8.26.0264 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 217-A e 129, §1º, do Código Penal e ainda fora preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, em que pese os réus sejam primários, os elementos constantes dos autos indicam, à saciedade, que se dedicam à prática de atos ilícitos, em especial o tráfico de drogas, fazendo dele seu meio de vida. Inviável, assim, a aplicação do redutor:

Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes - Conjunto probatório indicando que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes seu modo de vida - Não incidência da causa de diminuição - Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de antecedentes e da não participação em organizações criminosas, o fato de a apreensão ser referente a grande quantidade de entorpecente de maior poder viciante, no caso cocaína na forma de crack, indica que o apelante faz do tráfico o seu modo de vida, e demonstra o não preenchimento de outro requisito previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas. (...) (TJSP, Apelação Criminal nº 1500069-45.2020.8.26.0587, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, d.j. 17 de dezembro de 2021).

Pelas circunstâncias fáticas e pessoais - destacando-se o alto poder lesivo das drogas apreendidas, a participação de menor na atividade criminosa, o desemprego dos réus, o trâmite de ação penal na qual se apura a prática do mesmo crime (réu Alan), inúmeros antecedentes infracionais com cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade, internação e internação sanção (réu Wesley) - evidenciam que o regime inicial fechado é o único que se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime (artigo 33, §§2º e 3º c.c. artigo 59, caput, ambos do Código Penal).

Em razão da natureza do delito, não há que se falar em fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Com relação ao dinheiro apreendido, as circunstâncias autorizam concluir que se trata de proveito do crime, razão pela qual declaro o perdimento do montante depositado às fls. 128/129 em favor da União.

Não comprovada a utilização do celular apreendido em poder do menor K.F.R. na prática da infração penal, autorizo a restituição.

Às fls. 94 já fora determinada a destruição da droga apreendida. Com o trânsito em julgado, autorizo a destruição do entorpecente guardado para eventual contraprova. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os acusados ALAN SANTOS SILVA e WESLEY GUILHERME NOVAIS SANTOS, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, aplicando-lhes as penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, no mínimo a unidade.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual que ora lhes defiro, pois representados por procuradoras nomeadas nos termos do convênio DPE/OAB.

Arbitro, em favor das patronas nomeadas, honorários no teto da tabela DPE/OAB, observada a fase processual. Oportunamente, expeça-se certidão de honorários.

Nos termos da fundamentação supra, declaro o perdimento em favor da União dos valores depositados às fls. 128/129.

Autorizo, desde logo, a restituição do celular apreendido ao menor K.F.R.

O encaminhamento de cópia de peças processuais para eventual apuração independe de atuação judicial.

Presentes, ainda, os requisitos que autorizaram a prisão preventiva, em especial a necessidade de garantir a ordem pública e, diante da condenação criminal em primeiro grau, a aplicação da lei penal, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade. Expeçam-se Guias de Recolhimento Provisório, encaminhando-as aos estabelecimentos prisionais e ao Juízo da VEC competente.

Com o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal) e ao IIRGD. Oficie-se para destruição droga guardada para eventual contraprova.

P.I.C.

Itajobi, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA